

1523660-12.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278,

São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523660-12.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523660-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Henrique Martins e Lucas Nascimento da Silva

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Vistos etc.

Fernando Henrique Martins, qualificado à f. 19, Lucas Nascimento da Silva, qualificado à f. 21, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 69 do Código Penal, porque em 28 de setembro de 2021, por volta das 16h35min, na altura do n. 8 da Rua Salvador Faria de Albernaz, Cidade Ademar, nesta comarca de São Paulo, associaram-se com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, e nas mesmas circunstâncias, foram surpreendidos trazendo consigo e transportando, para fins de comércio, 820 porções de "maconha" (tetrahydrocannabinol - 2.288,6g), 555 pedras de "crack" (cocaína - 67,2g) e 130 porções da droga sintética denominada "K2" (ADB-BUTINACA- 26,1g), i sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.

Segundo consta, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o veículo RENAULT/KWID ZEN, branco, 2018/2019, placas FPX8F18, em circunstâncias que chamaram atenção e motivaram a abordagem.

FERNANDO o conduzia, em cujo bolso foram apreendidos R\$57,30. LUCAS ocupava o banco dianteiro do passageiro. Sobre o banco traseiro localizaram três sacolas com inscrições que indicavam seu destino - "ESMERALDA", "FERREIRA" e "HAWAI" -, a variedade e quantidade de drogas, tais como: "100 PEDRA", "100 M5", "50 M10", "25 M20", "30 K2". No interior dessas sacolas localizaram as porções de droga acima indicadas. Informalmente admitiram que esses entorpecentes se destinavam a abastecer as "biqueiras do 'Alba' e 'Vietnã'".

Denúncia recebida (fls. 144/145), os réus foram citados (fls. 191 e 194).

O réu Fernando Henrique Martins constituiu advogado, que apresentou defesa preliminar (f. 190).

A Defensoria Pública formulou a defesa do réu Lucas Nascimento da Silva (f. 210).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os réus.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública postulou aplicação de pena mínima, sustentando a circunstância atenuante de confissão para o réu Lucas, e a Defesa do réu Fernando postulou absolvição por falta de provas, subsidiariamente, aplicação de pena mínima.

Este o relatório.

Auto de exibição e apreensão (fl. 8), fotografias das sacolas e das drogas (fls. 58/59), laudo de constatação provisória (fls. 28/31) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 181/183), indicam resultados positivos para cocaína e tetrahydrocannabinol nas respectivas amostras periciadas, do total de 820 porções de "maconha" (tetrahydrocannabinol - 2.288,6g), 555 pedras de "crack" (cocaína - 67,2g).

Item 1 do auto de constatação à f. 28, número 320.765/2021 constatação inicial para droga sintética ADB-BUTINACA, canabinóide sintético, com presença do princípio ativo do tetrahydrocannabinol.

Está provada a materialidade delitiva, nos termos da denúncia.

Perícia do aparelho celular apreendido restou prejudicada, conforme apontamento de f. 257.

Em audiência de instrução:

PoliciaI Militar Fabio Meira Brandão relatou que durante patrulhamento, observou um veículo Renault Kwid de cor branca, quando os ocupantes fecharam os vidros ao perceberem a aproximação da viatura, sendo abordados em seguida, em vistoria ao veículos, foram encontradas seis sacolas, dentro de uma sacola plástica maior, sobre o banco traseiro do veículo, visíveis sobre o banco, com descrição dos tipos de drogas e das quantidades de entorpecentes, "havaí, ferreira, esmeralda" e ambos confessaram que estavam transportando entorpecentes para a comunidade Jd. Alba e imediações, mas não informaram a procedência, sendo aquela a primeira vez que foram pagos para transportar drogas, sendo apreendida ainda quantia em dinheiro de cinquenta e sete reais, com o condutor além de um telefone celular. Aquele que conduzia o veículo, em nenhum momento, disse que fazia uma "corrida informal". A partir do momento em que viram o policiaI iniciando as buscas dentro do carro, ambos logo admitiram que transportavam drogas. O veículo supostamente pertencia ao pai do condutor. Identificou os réus em audiência, não se recordando qual deles dirigia o veículo.

PoliciaI Militar Patrícia Correa, no mesmo sentido, confirmou que os réus foram abordados durante patrulhamento ostensivo de rotina, apenas porque subiram os vidros ao passarem pela viatura, sendo que, ao iniciar as buscas no interior do veículo, Fernando, que dirigia o carro, visualizando o interior e logo disse que transportavam drogas. Não conversou com o outro ocupante do veículo, que foi abordado pelo primeiro policiaI. Recordou-se dos réus apresentados em audiência, mas não soube precisar qual deles era o condutor do veículo. Às perguntas da defesa de Fernando, confirmou que "ele falou pra mim, era a primeira vez que transportava drogas, que pegou numa avenida próxima".

O réu Fernando Henrique Martins disse que não sabia que havia drogas dentro do carro que dirigia, carro pertencente ao seu pai, e não conhecia o Lucas, sendo que no dia anterior, foi contratado para transporta-lo de Santo André, Vila Giomar, com

destino à divisa de São Paulo com Diadema, embora não tivesse aplicativo de transporte instalado em seu celular, trabalhando apenas informalmente, e cobraria cento e cinquenta reais, recebendo antecipadamente cinquenta reais. A pessoa que lhe indicou o passageiro chama-se Márcia, não sabendo precisar sua qualificação, mas assegurou que ela lhe telefonou no mesmo celular que foi apreendido pelos policiais. Não esclareceu porque não forneceu sua senha de acesso ao celular para que os policiais verificassem tais contatos. Por fim, afirmou reiteradamente que o delegado lhe disse "mesmo eu assumindo a autoria das drogas eu ficaria preso porque ele queria seu carro para ele trabalhar, em nenhum momento pediram o documento que estava no aplicativo do celular".

O réu Lucas Nascimento da Silva disse que no dia anterior recebeu a proposta de setecentos reais para transportar drogas de São Paulo para Diadema, "peguei a mercadoria e fui para a casa de uma moça em Santo André, recebi mil e setecentos reais, ela falou que tinha um rapaz que fazia uns bicos particular, ela ligou para ele, conversou com ele, ele aceitou o valor de cento e cinquenta reais, deu cinquenta reais para ele, não falou para ele o que iria levar", no caminho ainda pararam para comer, e assim que saíram foram abordados por policiais, e ele respondeu apenas que estava fazendo "uma corrida", e assim que desceram do carro, confessou que trazia uma sacola com drogas e que o rapaz estava "fazendo uma corrida de Uber". Trazia consigo quantia entre trinta e quarenta reais. Trazia um celular, que "jogou antes de descer do carro, porque tinha as coisas do que estava carregando".

Em função da versão apresentada pelo réu Fernando, de que pretendia desbloquear seu celular perante o delegado para que pudesse comprovar sua versão, sobre os contatos realizados no dia anterior acerca da contratação informal para transporte de passageiro, seu advogado constituído optou por não dar continuidade à dilação probatória, afirmando categoricamente na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal que se dava por satisfeito com os apontamentos periciais constantes nos autos, que, conforme acima relatado, não são conclusivos, exatamente porque o celular não foi desbloqueado pelo réu por ocasião do flagrante.

Com efeito, se de fato alguém contratou o réu para transportar um desconhecido, cumpria à defesa arrolar tal pessoa, ou, por outra via, possibilitar o desbloqueio do celular apreendido com o réu, como único modo possível de prova para o apontado alibi, conforme expressamente determina o artigo 156 do Código de Processo Penal. Ademais, as versões evidentemente combinadas pelos réus, que permaneceram presos no mesmo local desde o flagrante, não convencem. Tanto assim, que após afirmaram que Lucas possuía cinquenta reais e que entregou tal quantia a Fernando antes de iniciarem a viagem, Lucas pretendeu acrescer sua versão, dizendo que almoçaram no caminho, e somente então afirmando que possuía mais dinheiro, com sobra de troco do almoço, além dos cinquenta reais que entregou para Fernando, quantia que não consta em auto de exibição e apreensão, à f. 8.

Com efeito, afastada a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "c", do Código Penal, porque fica reconhecido que os réus combinaram suas versões pretendendo omitir a verdade dos fatos e não confirmaram a narrativa inicial da denúncia quanto ao crime de tráfico.

Baseando-se em tais provas, sobre a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, ao contrário do que sustentou a defesa em alegações finais, devem ser acolhidos como elementos de prova, eis que uníssonos e coerentes com o teor do auto de prisão em flagrante, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade de que se revestem os atos dos agentes públicos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, e nesta ação penal não se tem qualquer indício de suspeição ou ilegalidade que possa macular o valor de tais depoimentos.

Reporto-me ao entendimento jurisprudencial:

PROVA CRIMINAL - Testemunha - Tráfico de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Inexistência de razão concreta para a suspeição - Relato firme e coerente - Apreensão da droga, ademais, presenciada por testemunha alheia aos quadros da polícia - Recurso não provido - JTJ 241/313.

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Prova criminal - Depoimento de policial participante

de diligência do flagrante - Testemunho coerente e seguro - Validade - RT 595/423. Neste contexto, inequívoco que os réus aceitaram participar de atividade organizada voltada para o tráfico de drogas, pois, incumbiram-se de transportar as drogas entre fornecedor não identificado e possíveis pontos de distribuição, que também não pretenderam identificar, ambos integrando cadeia criminoso entre procedência e destinação das drogas, assim agindo previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, incidindo ambos no núcleo do tipo penal do tráfico de drogas, nos termos do artigo 29 "caput" do Código Penal.

Entretanto, o crime autônomo de associação para o tráfico de drogas não ficou evidenciado no caso em análise, sendo essencial a demonstração do dolo específico, caracterizado pelo vínculo associativo em caráter permanente, e não apenas mera convergência eventual de propósitos criminosos. A coautoria ocasional, transitória, esporádica, eventual não configura crime de associação para o tráfico de drogas. Nesse sentido, com acerto a observação do eminente professor Vicente Greco filho, in Tóxicos, prevenção-repressão, 14ª edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2011: "Para haver crime autônomo de associação em matéria de entorpecentes é mister um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que determina a coautoria. É mister haja o dolo específico: associar para traficar (...) Diante, pois, destas considerações o crime de associação (art. 35) como figura autônoma há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples coautoria ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração...". No mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada" (STF, ROHC nº 75.236-5/AM, 1ª Turma, j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º- 8-1997, RT 749/584, citado por Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7ª edição, Editora Saraiva, p.232, grifei).

Parcialmente procedente a ação penal, com a condenação dos réus por crime de tráfico de drogas, afastado o concurso material com crime de associação para o tráfico de drogas.

Passo ao cálculo das penas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11343/06, e artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, em relação aos dois réus, deve ser considerada a grande quantidade de drogas, bem como o alto grau de toxidade da maior parte das drogas apreendidas, centenas de porções prontas para comercialização, com potencial de dano difuso à saúde pública devido ao grande número de usuários faz incidir a regra do artigo 42 da Lei nº 11.343, afastando a aplicabilidade da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, excluído o requisito subjetivo previsto em caráter excepcional para essa regra de cálculo da pena.

Fernando Henrique Martins ostenta condenação com pena extinta há mais de cinco anos da data do fato: Santo André - 3ª Vara Criminal, 0028888-83.2011.8.26.0554, que deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável, impondo-se acréscimo de pena de 1/6, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta dias multa. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal, circunstância objetiva da conduta, consistente em praticar crime em "qualquer calamidade pública", isto é, quem praticar crime em tal circunstância, independentemente de sua intensão, receberá tratamento legal diferenciado. O Decreto número 64879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade

pública no Estado de São Paulo decorrente da pandemia do Covid-19, foi largamente divulgado por todos meios de comunicação, de conhecimento, sendo inviável alegar ignorância da situação atual de pandemia. Inequívoco, portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação da doença e contágio coletivo, risco que o traficante assumiu e será apenado proporcionalmente à gravidade da conduta criminosa. A pena fica acrescida de 1/6, em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e setenta dias multa. Não constam outras circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal.

Lucas Nascimento da Silva ostenta duas condenações pretéritas que devem ser considerada na primeira fase da dosimetria, como antecedentes criminais, nos termos do artigo 59 do Código Penal, (São Bernardo do Campo - 5ª Vara Criminal, 0000966-11.2017.8.26.0537; São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal-0016234-24.2017.8.26.0564), acrescida a pena base de 1/5, em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa. Na segunda fase da dosimetria, pelo mesmo fundamento, aplicada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal, a pena fica acrescida de 1/6, em sete anos de reclusão e setecentos dias multa. Em função da reincidência específica em crime de tráfico, Diadema - 2ª Vara Criminal, 0012946-79.2018.8.26.0161, a pena fica acrescida de 1/6, em oito anos e dois meses de reclusão e oitocentos e dez dias multa. Não constam outras circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, para os dois réus, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, e o tempo de prisão descontado desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal não é compatível com a quantidade de pena aplicada e com a gravidade da conduta, ponderados os mesmos fundamentos da dosimetria da pena, tratando-se de conduta de consequências diferenciadas o crime de tráfico de quantidade maior de entorpecentes, que atenta seriamente contra a ordem pública e acarreta manifesto risco à ordem e segurança pública, fomento de diversas atividades criminosas ainda mais graves, merecedora de tratamento legal diferenciado, em resguardo ao caráter preventivo da pena, para que sirva de efetivo desestímulo à reiteração da conduta pelo criminoso que se dispõe a distribuir drogas em bairro residencial densamente habitado, de modo a expor a risco não só os usuários como potenciais adquirentes de drogas ilícitas, mas principalmente todos aqueles que, alheios à sua atividade criminosos, são obrigados a conviverem diariamente sob a nefasta ameaça do tráfico de drogas.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, por não existir prova de condição econômica dos condenados, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal. Condene o réu Fernando Henrique Martins, qualificado à f. 19, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/2006, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal. Condene o réu Lucas Nascimento da Silva, qualificado à f. 21, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/2006, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dez dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal.

Ao trânsito em julgado, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal. Condene os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003), suspensa a exigibilidade em relação ao réu assistido pela Defensoria Pública.

Os réus foram presos em flagrante, responderam presos ao processo e subsistentes os

fundamentos da prisão cautelar, conforme decidido no curso da ação penal, não poderão recorrer em liberdade, nos termos do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 8072/90. Para efeitos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão desde a data do flagrante não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, expedindo-se oportunamente guias de execução.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA